

ASMAWI BIN MUHAMAD NOR

lwn.

ZAIMIRA BINTI JAILANI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mohd Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 22 Jun 2020 bersamaan 30 Syawal 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-026-0036-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Ubah Perintah Hak Jagaan Anak Di Bawah Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tiada.

Peguam Syarie Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 30 April 2019 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 29 April 2019 dalam Kes Saman No. : 10400-026-0428-2016 sepertimana berikut –

1. Tuntutan Plaintiff ditolak.

[2] Perayu iaitu Plaintiff di dalam Kes Saman No. : 10400-026-0428-2016 telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 28 Ogos 2019 yang mengandungi dua (2) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 480 - 481 sepertimana berikut –

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang bahawa isu aurat dan hubungan keluarga di antara 2 orang anak angkat (sepasang) Perayu, anak kandung perempuan Perayu yang telah baligh, bakal anak tiri dan bakal bapa tiri mereka tidak boleh tinggal dalam satu rumah bersama adik lelaki bujang Responden dan bapa Responden juga.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang akan keterangan Perayu yang menzahirkan bukti akan keputusan pencapaian akademik yang semakin merosot pada setiap tahun anak-anak angkat dan anak kandung Perayu, perilaku serta sikap mereka yang telah tidak menitikberatkan amalan agama Islam seharian dan mereka juga telah mulai lalai serta leka akan peranan masing-masing dalam hal seharian.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 3 September 1999 di Bukit Lanchong, Shah Alam, Selangor dan telah disahkan bercerai secara fasakh pada 28 Januari 2016 oleh Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Hasil daripada perkahwinan, mereka telah dikurniakan dengan seorang cahayamata perempuan yang diberi nama ASFA HURIN BINTI ASMAWI yang dilahirkan pada 11 November 2005. Di samping itu pasangan ini juga mempunyai sepasang anak angkat bernama AMMAR IRSYAD ASMAWI yang dilahirkan pada 26 Mei 2004 dan AMNI WIDAD ASMAWI yang dilahirkan pada 22 Oktober 2003.

[4] Pada 8 Disember 2015, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah melalui kes Saman No: 10300 028 0210 2015 yang antara lain memberikan hak jagaan kekal anak-anak tersebut kepada Responden manakala Perayu diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam pada masa-masa yang telah ditetapkan.

[5] Perayu telah membuat permohonan untuk mengubah perintah hak jagaan anak pada 12 Julai 2016 iaitu anak-anak bernama AMNI WIDAD ASMAWI dan ASFA HURIN BINTI ASMAWI diletakkan di bawah jagaan Perayu manakala Responden diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam pada setiap minggu keempat.

[6] Permohonan mengubah perintah hak jagaan tersebut adalah bersandarkan alasan - alasan berikut :

- 6.1 Anak-anak telah mencapai umur mumaiyiz dan ingin membuat pilihan sendiri.
- 6.2 Defendan (Responden) telah cuai dan mengabaikan kebajikan serta menganiaya anak tersebut dengan cara menghasut anak-anak supaya mengeji dan menghina Plaintiff (Perayu) dan tunang menyebabkan anak-anak tidak menghormati Perayu, ibu Perayu serta tunang.
- 6.3 Responden telah menafikan hak Perayu untuk bersama anak tersebut dengan cara sering lewat menghantar anak-anak ke balai dan menggunakan alasan kelas tambahan supaya anak-anak enggan bersama Perayu ketika giliran Perayu tiba.

6.4 Responden telah berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka dengan cara menghantar sms/whatsapp dengan bahasa kasar/biadap melalui telefonnya juga telefon anak.

[7] Semasa peringkat perbicaraan, kedua-dua Perayu dan Responden telah memfailkan Affidavit Keterangan dan kedua-dua Perayu dan Responden telah menyoalbalas pihak yang satu lagi. Perayu juga telah mengemukakan seorang saksi dan memfailkan Affidavit Keterangan Saksi. Mahkamah Bicara juga telah mengambil keterangan ketiga-tiga anak kandung dan anak angkat pasangan ini.

[8] Pada 29 April 2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sepertimana perenggan 1 di atas. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 30 April 2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh kedua-dua pihak Perayu dan Responden. Kami dapati bahawa walaupun Perayu telah mengemukakan dua (2) Alasan Rayuan sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini di perenggan 2 penghakiman ini tetapi Perayu semasa berhujah telah menghujahkan berdasarkan tiga (3) hujahan iaitu :

- i) Adakah wajar anak gadis tinggal sebumbung bersama bukan mahramnya;

- ii) Responden telah gagal menyediakan pendidikan yang sewajarnya kepada anak-anak tersebut; dan
- iii) Responden telah gagal memberikan didikan agama kepada anak-anak tersebut

[10] Oleh yang demikian berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan pihak Perayu, kami akan merangkumkan hujahan kedua dan ketiga pada alasan rayuan kedua manakala hujahan pertama akan diulas secara berasingan.

Isu Pertama : Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang bahawa isu aurat dan hubungan keluarga di antara 2 orang anak angkat (sepasang) Perayu, anak kandung perempuan Perayu yang telah baligh, bakal anak tiri dan bakal bapa tiri mereka tidak boleh tinggal dalam satu rumah bersama adik lelaki bujang Responden dan bapa Responden juga.

[11] Perayu menghujahkan bahawa adalah tidak manis bagi seorang anak gadis seusia anak kandung pasangan ini yang sudah mencecah umur baligh untuk tinggal bersama keluarga Responden di rumah yang turut didiami oleh adik lelaki Responden yang masih bujang dan bapa Responden (yang disifatkan oleh Perayu sebagai lelaki bukan mahram kepada anak tersebut).

[12] Perayu juga menyatakan bahawa kebimbangannya terhadap nasib anak tersebut semakin bertambah apabila mendapat makluman bahawa Responden bakal berkahwin tidak lama lagi dan seeloknya anak-anak tersebut tinggal bersama Perayu selaku bapa kandung dan bapa angkat yang telah membesarkan anak-anak tersebut berbanding bapa tiri yang baru dikenali.

[13] Responden di dalam hujahannya mengakui bahawa anak angkat perempuannya adalah bukan mahram dengan bapa dan adik lelaki Responden tetapi anak angkat tersebut sentiasa menjaga auratnya di hadapan bukan mahram malah kesemua anak-anak Responden sangat menjaga pergaulan mereka serta tidak melebihi batasan.

[14] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara iaitu daripada muka surat 459 - 468 Rekod Rayuan dan kami tidak mendapati apa-apa ulasan YA Hakim Bicara berkenaan isu yang dibangkitkan oleh Perayu ini.

[15] Sebaliknya YA Hakim Bicara di perenggan 4 Alasan Penghakiman iaitu di dalam muka surat 464 - 465 Rekod Rayuan telah menyatakan seperti berikut -

“ Berdasarkan Afidavit Keterangan Plaintiff tersebut Mahkamah dapati tiada keterangan yang jelas tentang kehendak Plaintiff dalam kes ini dan tiada penjelasan lanjut mengenai alasan-alasan yang telah Plaintiff nyatakan dalam Penyata Tuntutannya. Apa yang lebih mengelirukan Mahkamah ini lagi adalah Plaintiff dalam Afidavit Keterangan tersebut telah menyatakan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan kes ini. ”

[16] Kami dengan hormatnya bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara seperti di dalam perenggan 3 Alasan Penghakiman iaitu di muka surat 464 Rekod Rayuan bahawa perubahan perintah hadhanah adalah dibenarkan dengan syarat pihak-pihak perlu membuktikan kepada Mahkamah bahawa Perintah yang dikeluarkan tersebut telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau telah berlaku perubahan matan tentang keadaan anak atau pihak-pihak tersebut.

[17] Bagi maksud mengulas alasan rayuan pertama ini kami telah meneliti Rekod Rayuan iaitu Penyata Tuntutan di muka surat 4 - 6, Afidavit Keterangan Plaintif di muka surat 138 - 143 dan Keterangan Plaintif ketika disoalbalas oleh Defendan di muka surat 436. Kami dapati bahawa isu berkenaan tempat tinggal anak-anak tersebut dan isu hubungan mahram dengan pihak-pihak yang turut tinggal bersama dengan anak-anak tersebut tidak pernah dibangkitkan oleh Perayu sebagai alasan Perayu untuk memohon perubahan perintah hadhanah anak-anak tersebut. Isu mengenai perkahwinan yang bakal berlaku di antara Responden dengan seseorang yang akan menjadi bapa tiri kepada anak-anak tersebut juga tidak pernah ditimbulkan oleh Perayu sebagai alasan di dalam kes perubahan perintah hadhanah.

[18] Walaubagaimanapun kami dapati pada muka surat 59 Rekod Rayuan, Perayu telah mengemukakan satu laporan polis bertarikh 18 April 2015 sebagai salah satu daripada ekshibit kepada Jawapan Kepada Pembelaannya yang ditandakan sebagai AMN-3 berkaitan kebimbangan Perayu akan berlakunya sumbang mahram di antara bapa mertua, adik ipar lelaki dan perempuan dengan anak kandung serta anak-anak angkat Perayu yang tinggal sebumbung. Manakala isu tentang perkahwinan baru Responden yang bakal berlaku telah disuarakan oleh Perayu di dalam Jawapan Kepada Pembelaan iaitu di muka surat 34 Rekod Rayuan. Kedua-dua isu ini bagaimanapun telah tidak diperjelaskan sepanjang perbicaraan.

[19] Oleh yang demikian kami berpendapat isu kepada alasan rayuan ini adalah bersandarkan semata-mata kepada andaian Perayu semata-mata dan bukannya satu fakta yang telah dibuktikan. Oleh yang demikian kami tidak dapat mempertimbangkan alasan rayuan ini.

Isu Kedua : Hakim Bicara tersilap dari segi fakta dan undang-undang akan keterangan Perayu yang menzahirkan bukti akan keputusan pencapaian akademik yang semakin merosot pada setiap tahun anak-anak angkat dan anak kandung Perayu, perilaku serta sikap mereka yang telah tidak menitikberatkan amalan agama Islam seharian dan mereka juga telah mulai lalai serta leka akan peranan masing-masing dalam hal seharian

[20] Perayu menghujahkan bahawa Responden telah gagal menyediakan pendidikan yang mampan kepada anak-anak tersebut. Ini terbukti apabila keputusan peperiksaan anak-anak tersebut semakin merosot dan kurang memberangsangkan sedangkan sebagai seorang guru, Responden seharusnya lebih bijak menguruskan hal-hal berkaitan pendidikan anak-anak tersebut dan mencari inisiatif untuk meningkatkan tahap pendidikan anak-anak tersebut.

[21] Perayu juga menghujahkan bahawa Responden telah gagal mengawal selia dan tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga anak-anak tersebut dengan baik. Ini adalah kerana kebelakangan ini Perayu dapati anak-anak tersebut sudah mula meninggalkan solat sedangkan sepanjang tempoh anak-anak bersama Perayu, Perayu cuba sebaiknya memastikan anak-anak tersebut melakukan solat lima waktu dengan sebaiknya serta sering membawa mereka ke masjid dan majlis-majlis ilmu yang bermanfaat.

[22] Responden pula menghujahkan bahawa sebagai pihak yang telah diberikan hak jagaan anak-anak tersebut, Responden telah menyediakan keperluan persekolahan, menguruskan pengangkutan anak-anak ke sekolah dan membimbing mereka mengulangkaji pelajaran. Responden mengakui bahawa anak-anak di

bawah jagaannya mungkin tidak cemerlang dan terbilang di dalam akademik tetapi kejayaan seorang anak tidak boleh diukur dari segi akademik semata-mata.

[23] Responden seterusnya menghujahkan bahawa anak-anak di bawah jagaannya masih mengamalkan ajaran Islam. Anak-anak tersebut tidak dihalang dari melaksanakan suruhan Allah malah disediakan kelengkapan untuk beribadah.

[24] Kami sekali lagi telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara iaitu daripada muka surat 459 - 468 Rekod Rayuan dan kami tidak mendapati apa-apa ulasan YA Hakim Bicara berkenaan isu yang dibangkitkan oleh Perayu ini.

[25] Sepertimana yang kami telah jelaskan di dalam perenggan 16 di atas bahawa YA Hakim Bicara di perenggan 4 Alasan Penghakiman iaitu di dalam muka surat 464 - 465 Rekod Rayuan telah menyatakan seperti berikut -

“ Berdasarkan Afidavit Keterangan Plaintiff tersebut Mahkamah dapati tiada keterangan yang jelas tentang kehendak Plaintiff dalam kes ini dan tiada penjelasan lanjut mengenai alasan-alasan yang telah Plaintiff nyatakan dalam Penyata Tuntutannya. Apa yang lebih mengelirukan Mahkamah ini lagi adalah Plaintiff dalam Afidavit Keterangan tersebut telah menyatakan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan kes ini. ”

[26] YA Hakim Bicara juga selanjutnya berpendapat seperti berikut –

“ ...bahawa Plaintiff telah gagal untuk menjelaskan kepada Mahkamah ini dengan sewajarnya alasan-alasan tuntutan Plaintiff di dalam kes ini.”

[27] Bagi maksud mengulas alasan rayuan kedua ini kami telah meneliti Rekod Rayuan dan mendapati bahawa Perayu telah membangkitkan kekesalan Perayu berkenaan ketidakhadiran anak-anak tersebut ke sekolah selama hampir 9 bulan iaitu di dalam Jawapan Kepada Pembelaan di muka surat 31 Rekod Rayuan, Afidavit Keterangan Plaintiff di muka surat 139 Rekod Rayuan seterusnya di dalam Keterangan Plaintiff di muka surat 436 Rekod Rayuan tetapi kami tidak menemui sebarang bukti seperti yang diujahkan oleh Perayu mengenai pencapaian akademik anak-anak tersebut yang dikatakan semakin merosot pada setiap tahun.

[28] Kami dengan hormatnya ingin mengatakan bahawa beban pembuktian sesuatu fakta adalah terletak di atas Perayu selaku Plaintiff di dalam kes yang ingin dirayu sepertimana yang telah diperuntukkan di dalam Seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut –

Seksyen 73. Beban membuktikan.

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

[29] Kami juga mendapati bahawa isu berkenaan perilaku serta sikap anak-anak yang telah tidak menitikberatkan amalan agama Islam seharian dan mereka juga telah mulai lalai serta leka akan peranan masing-masing dalam hal seharian adalah

satu fakta baru yang tidak pernah dikemukakan semasa kes bicara. Kami merujuk kepada Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004 yang telah memberikan garis panduan kepada kami mengenai fakta baru semasa prosiding rayuan iaitu -

***Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004
Tambahan Fakta Baru Semasa Prosiding Rayuan***

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil 1 Tahun 2004 pada 8 – 9hb.Jun 2004 bersamaan 19 – 20hb Rabiulakhir 1425H di Subang Jaya, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung tambahan fakta baru semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan.

[30] Oleh yang demikian kami tidak dapat mempertimbangkan alasan rayuan ini berdasarkan undang-undang yang tidak membenarkan pendengaran apa-apa fakta baharu dalam prosiding rayuan.

[31] Kami tegaskan sekali lagi bahawa kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa di dalam kes permohonan ubah perintah hadhanah, apa yang perlu dititikberatkan oleh seseorang Plaintiff adalah keperluan untuk membuktikan kepada Mahkamah bahawa Perintah yang dimohon untuk diubah tersebut telah diasaskan oleh sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau telah berlaku perubahan matan tentang keadaan anak atau pihak-pihak tersebut.

[32] Kami seterusnya ingin menasihatkan pihak-pihak bahawa tindakan undang-undang yang sewajarnya diambil terhadap kegagalan mana-mana pihak mematuhi sesuatu Perintah adalah tindakan pelaksanaan undang-undang.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **Y.A.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A. DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

